

1500968-23.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EXPEDITO DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

19/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500968-23.2022.8.26.0571 - Controle 2022/001159

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EXPEDITO DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

19/10/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes, verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública. Ausente o acusado Gabriel Expedito de Oliveira, que se encontra em liberdade e foi devidamente intimado às fls. 79. Ausente também o policial militar Vanclei Benedito Fogaça, requisitado às fls. 71. Foi ouvida a testemunha André Luiz Souza Vieira arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Vanclei Benedito Fogaça, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O depoimento foi registrado pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Decreto a revelia do réu e não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 02h05, na Rua José Pércio dos Santos, nº 605, Vila Arruda, nesta cidade e comarca de Itapetininga, trazia consigo e guardava, para comercialização a terceiros, 18 (dezoito) microtubos de cocaína, com peso líquido de 2,14g (dois gramas e quatorze centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 58) e apresentou defesa prévia (fls. 62/63). A denúncia foi recebida em 22/08/2022 (fls. 65/66) e o acusado foi citado (fls. 79). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu não foi interrogado. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de constatação (fls. 17/18) e pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 41/44). A autoria também foi devidamente demonstrada. Vejamos. Em solo policial, o réu negou a prática dos fatos. Disse que foi abordado pelos policiais enquanto esperava uma corrida de "Uber" para ir até a residência de sua namorada. Falou que os militares encontraram droga em uma lixeira. Assumiu, contudo, a condição de usuário de entorpecentes (fls. 05). Em Juízo, optou pela revelia. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento, momento em que um transeunte lhes informou que o indivíduo chamado GABRIEL estava comercializando entorpecentes no local, sendo que ocultava as drogas no canteiro da via pública. Então, em diligências, os policiais avistaram o denunciado, que possuía as características físicas e de vestimentas informadas na denúncia apócrifa, mexendo no canteiro da via pública. Ocorre que, ao perceber a presença da viatura, GABRIEL prontamente dispensou algo ao chão e, diante disso, os policiais decidiram abordá-lo. Assim, em revista pessoal, os policiais encontraram com o denunciado o valor de R\$ 10,00 (dez reais). Ato contínuo, os policiais analisaram a sacola que GABRIEL havia dispensado antes da abordagem e, então, encontraram 18 (dezoito) pinos de cocaína. GABRIEL foi preso em flagrante delito. Pois bem. Agora, o policial André afirmou que patrulhava com o colega pelo local quando foi abordado por um transeunte. Ele especificava que o réu - GABRIEL - fazia tráfico pelo local, dava as características físicas e o modo de atuação do réu. Então, para lá se dirigiram. Chegando ao local, depararam-se com o réu, abaixado, mexendo em um canteiro. Ao notar a viatura, o réu jogou um pacote no chão, com as porções descritas na denúncia. O réu dizia que esperava um "UBER", mas morava na rua de baixo. Assim, a prova é firme ao incriminar o acusado. As circunstâncias da apreensão das drogas, tais como a denúncia do transeunte no sentido de que indivíduo chamado GABRIEL estaria comercializando entorpecentes no local e acondicionando as drogas no canteiro da via pública, o fato de o denunciado encontrar-se no local apontado mexendo no canteiro e possuir as características físicas e de vestimentas informadas na denúncia, a conduta do denunciado de dispensar a sacola contendo os entorpecentes ao perceber a presença da viatura, a natureza extremamente nociva e a localização de considerável quantidade de drogas, bem como a forma de acondicionamento delas, em porções individuais, prontas para a venda, além da localização de quantia em dinheiro, não deixam dúvidas de que os narcóticos se destinavam ao tráfico. De mais a mais, a testemunha também afastou a hipótese do "UBER". Registre-se que nada está a indicar que a testemunha esteja a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes, de modo que merecem todo crédito. Dessa forma, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a integral procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 21/23). Cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. O regime prisional poderá ser o inicialmente aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com decretação do perdimento dos valores apreendidos. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: A Defensoria Pública representa o acusado, que foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão persecutória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado, pelas razões a seguir. I. DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. Da absolvição por insuficiência de provas. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se

autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. O policial André Luiz de Sousa Vieira, ouvido em juízo, declarou que estava em patrulhamento com seu colega de farda e um transeunte parou a viatura, informando que um indivíduo de nome Gabriel estaria vendendo drogas e esconderia os entorpecentes em um canteiro. Ao entrar na rua, visualizaram uma pessoa agachada num canteiro. Quando essa pessoa levantou, avisou a viatura e jogou um saquinho no chão. Nesse saquinho, havia 18 pinos de cocaína. Ouvido no local, negou que as drogas lhes pertenciam e disse que que estava no local para pegar um uber. Em que pese o réu não ter comparecido em juízo, já em solo policial negou veementemente as imputações. Disse que as drogas não lhe pertenciam. Informou que trabalha em uma pizzaria e que não estava vendendo drogas. É certo, portanto, que a denúncia não se sustenta: em primeiro lugar, apenas um policial (responsável pela abordagem) foi ouvido em juízo, não havendo nenhuma outra testemunha dos fatos. Além disso, nada de ilícito foi apreendido em poder do réu, sendo que os entorpecentes teriam sido localizados na sacola no chão. Ainda, o suposto transeunte que teria informado à polícia que um sujeito estava vendendo drogas sequer foi identificado e ouvido formalmente. Assim, não há absolutamente nada de concreto que indique a prática delitiva por parte do réu. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II- DA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. Requisitos legais preenchidos. Na hipótese vertente, encontram-se presentes todos os requisitos para a sua incidência, vez que o acusado é primário e tem bons antecedentes. Ademais, não há prova de que ele participe de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades ilícitas, o que não pode ser presumido. Neste ponto, cumpre ressaltar que, para que ocorra “dedicação às atividades criminosas”, faz-se necessário que o agente pratique não um ou dois crimes, mas diversos atos ilícitos periodicamente, que faça de sua atividade cotidiana o cometimento de crimes, o que, no caso, não se deu, à vista da primariedade do denunciado. Finalmente, cabe observar que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a quantidade de entorpecentes apreendida não basta, por si só, para afastar a incidência do redutor, se presentes seus requisitos legais. Na mesma linha, é o entendimento doutrinário, como bem aponta Luiz Flávio Gomes, verbis: “No delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1º), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo individual e ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal. A simples leitura do parágrafo pode induzir o intérprete a imaginar que o benefício está na órbita discricionária do juiz. Contudo, parece-nos que, preenchidos os requisitos, o magistrado não só pode como deve reduzir a pena, ficando sua discricionariedade (motivada) limitada à fração minorante (esta orientada pela quantidade e/ou espécie de droga apreendida” (Lei de Drogas Comentada, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 178 – grifado). Assim, plenamente identificados os requisitos

legais, deve incidir a hipótese de redução estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III- TESES SUBSIDIÁRIAS. Em caso de condenação, na primeira fase da dosimetria das reprimendas, cabe ressaltar que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal, eis que a culpabilidade da ação do acusado não extrapola aquela inerente ao respectivo tipo penal, não tendo havido, ainda, maiores consequências da prática delitiva. Finalmente, quanto ao regime inicial, requer que seja fixado regime inicial aberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33 do Código Penal, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Pugna-se, por fim, com fundamento no art. 8º, item 2, ‘h’, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. GABRIEL EXPEDITO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi

denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 02 h e 05 min, na Rua José Pércio dos Santos, n. 605, Vila Arruda, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezoito microtubos contendo "cocaína", com peso de 2,14 gramas. Notificado, fls. 58, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 62/63. A denúncia foi recebida, fls. 64/65 e o Réu, citado, fls. 79. Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha presente. Foi decretada a revelia do Réu. Alegações finais apresentadas pelas partes, o MP pugnou a condenação e a Defesa, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito de tráfico acha-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, fls. 11/12, no Auto de Exibição e Apreensão, fls. 14, no Laudo de Constatação, fls. 17/18, bem como no Exame químico-toxicológico n. 227.908/2022, fls. 41/44, constatando-se a presença do princípio ativo cocaína. André Luiz Souza Vieira, policial militar, testemunha, disse que estavam em patrulhamento e foram acionados por um transeunte, o qual narrou o tráfico de entorpecentes e descreveu a pessoa e deu o nome dela; disse também que os entorpecentes ficavam ocultos no canteiro da via pública; os policiais foram ao local e identificaram o Réu, o qual, ao ver a viatura, dispensou algo; o Acusado foi submetido à busca pessoal e, com ele, houve apreensão de R\$ 10,00; verificado o que havia sido dispensado, os policiais encontraram 18 pinos de "cocaína". Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a condenação é medida que se impõe. Com efeito, os policiais estavam em serviço quando receberam informações de tráfico de entorpecentes e, ao chegarem ao local, viram o Réu, que mexia naquele ponto, dispensar algo, e, com ele, os policiais encontraram a quantia de R\$ 10,00; os policiais verificaram o que havia sido dispensado e encontraram um saco 18 pinos de "cocaína". Com toda certeza o Réu, para poder vender, utilizava o local, canteiro da via pública, para esconder as porções, e os policiais encontraram, dentro de um saquinho, drogas que, pela quantidade, forma de partilha e todas as circunstâncias já descritas, destinavam-se ao comércio ilícito. No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais e agentes da lei, há que se considerar que, por se tratarem de agentes públicos, gozam da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos. Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito: "É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, condutas estas que configuram a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo e guardar, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede integralmente. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais, razão pela qual fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. Art. 61 e art. 65, do CP: Não há. Art. 68, do CP: Considerando-se a quantidade de entorpecentes, aplico a causa de diminuição de pena e a reduzo em 2/3. Fixo-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e de 166 (cento e sessenta e seis) dias - multa, no piso, que torno definitiva. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a

inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa “empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da Resolução n.º 5/12, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). O Superior Tribunal de Justiça já vem se alinhando àqueles entendimentos, conforme se viu no julgamento do Habeas Corpus 176.919/DF, onde foi concedida a ordem para estabelecer o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e para substituir esta por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2010, Dje 13/12/2010). Na hipótese, o réu havia sido condenado por tráfico de drogas, lhe sendo imposta uma sanção de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, tendo sido reconhecida a sua primariedade e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Portanto, em razão da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, o Réu poderá cumprir a pena no regime aberto, já considerada a detração. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, e limitação de fim de semana. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar GABRIEL EXPEDITO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias – multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário - mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, “caput”, da Lei n.º. 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, a prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de liberdade, e limitação de fim de semana. Deixo de condenar o Réu nas custas, ante a pobreza presumida. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, neste momento, ausentes as razões da custódia cautelar, poderá interpor eventual recurso nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 19 de outubro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA